

1502253-90.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... afirmando que aceitou trabalhar no tráfico, por necessidade, para ele e sua mulher grávida não ficarem na chuva, porque seu barraco caiu. Disse que fazia "bicos" como ajudante, mas não estava achando nenhum trabalho e pediam dinheiro na rua. Tem condenação por roubo e tráfico. Pediu uma oportunidade.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 08/09), disseram que estavam em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502253-90.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502253-90.2021.8.26.0537 Controle nº 1616/2021

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FELIPE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JEFFERSON FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 13:30 horas, na Passagem Nova Esperança, altura do número 336, Bairro Inamar, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão de juíza de plantão (fls. 46/49).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 98), sendo recebida a denúncia em 16.02.22 (fls. 147/148). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi

instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º 2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, por ser duplamente reincidente, com aumento pela reincidência específica, que a condenação por roubo seja compensada com a confissão judicial, fixação de regime fechado, afastando-se a redução do art. 33, §4.º.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação a fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado permaneceu calado (fls. 10). Em juízo, confessou a prática do crime, afirmando que aceitou trabalhar no tráfico, por necessidade, para ele e sua mulher grávida não ficarem na chuva, porque seu barraco caiu. Disse que fazia "bicos" como ajudante, mas não estava achando nenhum trabalho e pediam dinheiro na rua. Tem condenação por roubo e tráfico. Pediu uma oportunidade.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 08/09), disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o réu parado na via pública, com uma sacola de mercado nas mãos. Relataram que ao se aproximarem o réu tentou fugir correndo, porém, o detiveram. Narraram que ao verificarem a sacola que o réu trazia consigo encontraram no interior dela 29 invólucros de cocaína, 102 invólucros de maconha, 42 pedras de "crack" e a quantia de R\$ 29,00. Falaram que o réu se recusou a responder se estava traficando as drogas. Então o prenderam e conduziram ao distrito policial.

Flávio (policial), em juízo, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu estava sozinho e parado. Narrou que ao desembarcar da viatura e mandar levantar as mãos o réu se evadiu. Disse que abordaram o réu e na sacola que estava em poder deste havia drogas e dinheiro.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 08/09 e 11/12 - 29 invólucros de cocaína, 102 invólucros de maconha e 42 pedras de "crack"), a confissão judicial, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pela conduta de trazer consigo.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 17/19) e laudo definitivo (fls. 69/71). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 23 – proc. 29789-69.2015 por roubo). Quanto à condenação por tráfico ocorreu a extinção pela prescrição (fls. 24).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (29 invólucros de cocaína, 102 invólucros de maconha e 42 pedras de "crack", já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Compenso a reincidência com a confissão judicial, pelo que a pena permanece inalterada.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico. Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo qualificado (fls. 23 – proc. 29789-69.2015), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 12.11.21).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) e de ter sido praticado o crime durante a pandemia COVID, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JEFFERSON FELIPE DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03). Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 11 e 68) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06). Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 50), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Diadema, 17 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA